

<제2편 소송의 주체.제04장 당사자.제02절 당사자의 자격>

[예상][4.02-1]당사자능력과 당사자적격의 비교

《【문제4.2】 당사자능력과 당사자적격에 대해 설명하시오.》

<문제4.2> 당사자능력과 당사자적격의 비교

I. 당사자조건의 의의

- 민사소송이 적법하게 개시되고 진행되기 위해서는 소송의 주체인 당사자가 일정한 요건을 갖추어야 한다. 이를 당사자 조건이라 하며, 대표적으로 당사자능력과 당사자적격이 있다. 두 개념은 모두 소송요건에 해당하여 법원의 직권조사사항이라는 공통점이 있으나, 그 자격의 성질과 구체적인 판단 기준에서 명확히 구분된다. 실무상 이를 혼동할 경우 소송 요건의 흠결로 소각하 판결을 받게 되므로 명확한 구별이 필수적이다.

II. 당사자능력의 개념 및 법적 성격

1. 당사자능력의 정의

- 당사자능력이란 소송의 당사자(원고 또는 피고)가 될 수 있는 추상적·일반적인 자격을 의미한다. 이는 실체법상 민법의 권리능력에 대응하는 소송법상의 개념이다. 따라서 권리를 가질 수 있는 자는 당연히 소송의 당사자가 될 수 있는 자격을 가진다.

2. 당사자능력자의 범위

(1) 자연인과 법인

- 모든 자연인(외국인, 미성년자 포함)과 법인은 권리능력을 가지므로 당연히 당사자능력을 가진다. 태아의 경우 민법상 개별 규정에 의해 권리능력이 인정되는 범위 내에서 예외적으로 소송법상 당사자능력이 인정될 수 있다.

(2) 비법인 사단·재단 [민사소송법 제52조]

- 민법상 권리능력은 없으나 사단 또는 재단으로서의 실체를 갖추고 대표자나 관리인이 지정되어 있는 경우, 소송법상 예외적으로 당사자능력을 인정한다. 종종, 동창회, 아파트 입주자대표회의 등이 이에 해당한다.

(3) 민법상 조합의 예외

- 민법상 조합은 사단성이 결여되어 원칙적으로 당사자능력이 부정되며, 조합원 전원이 공동소송인으로 참여하여야 한다.

III. 당사자적격의 개념 및 법적 성격

1. 당사자적격의 정의

- 당사자적격이란 특정한 소송물에 대하여 원고(원고적격) 또는 피고(피고적격)로서 소송을 수행하고 판결을 받을 수 있는 구체적·개별적인 자격을 의미한다. 당사자능력이 소송에 참여할 수 있는 기본 자격이라면, 당사자적격은 당해 특정 재판의 당사자로서 적합한 자격이다.

2. 적격의 판단 기준

(1) 일반적 기준(관리처분권)

- 주로 실체법상의 권리관계에 기하여 결정된다. 즉, 소송의 대상이 된 권리나 법률관계의 주체인 자가 당사자적격을 갖는다. 이행의 소에서는 원고가 자기에게 권리가 있다고 주장하는 자가 원고적격을 갖고, 그로부터 이행을 청구받은 자가 피고적격을 갖는 것이 원칙이다.

(2) 제3자의 소송담당

- 실체법상 권리 주체가 아님에도 불구하고 법률의 규정(예 : 채권자대위소송에서의 채권자)이나 당사자의 지정에 의해 제3자가 당사자적격을 취득하여 소송을 수행하는 예외적인 형태가 존재한다.

IV. 두 개념의 주요 차이점 비교

1. 추상적 자격과 구체적 자격의 차이

- 당사자능력은 당해 사건의 내용과 무관하게 누가 소송의 주체가 될 수 있는가에 관한 추상적인 자격이다. 반면, 당사자적격은 특정 사건에 대하여 누가 재판을 이끌어갈 책임자인가를 묻는 구체적인 자격이다. 예를 들어, 자연인 A는 당사자능력을 언제나 가지지만, 타인의 채무 관계에 관한 소송에서는 당사자적격이 없다.

2. 실체법적 대응 개념의 차이

(1) 당사자능력

- 민법의 권리능력과 대응한다.

(2) 당사자적격

- 민법상의 소유권이나 채권 등 관리처분권과 대응한다. 따라서 재산의 처분 권한이 제한된 파산관재인 등은 원래 소유자가 당사자능력이 있음에도 불구하고 법률에 의해 당사자적격을 독점하게 된다.

3. 흠결 시 효과와 소송절차상의 차이

(1) 당사자능력의 흠결

- 소송 제기 당시 당사자능력이 없는 자(예 : 사망자, 존재하지 않는 단체)를 당사자로 삼은 경우, 원칙적으로 보정이 불가능하며 법원은 소를 각하하여야 한다. 다만 당사자 표시정정 등으로 해결할 수 있는 예외적 범위가 좁게 인정된다.

(2) 당사자적격의 흠결

- 소송 도중 당사자적격이 없는 자가 소를 제기한 것이 밝혀지면 역시 소각하 판결을 내린다. 그러나 임의적 당사자변경이나 소송인수, 소송참가 등의 소송법적 장치를 통해 적격이 있는 자로 당사자를 교체하거나 보정할 수 있는 여지가 당사자능력에 비해 상대적으로 넓다.

V. 관련 판례 및 실무적 적용

1. 사망자를 피고로 한 소송

- “판례”는 소 제기 전에 이미 사망한 자를 피고로 하여 소를 제기한 경우, 그 소송은 당사자능력이 없는 자를 상대로 한 것이므로 부적법하여 각하되어야 한다고 본다. 다만, 소 제기 후에 사망한 경우에는 소송절차가 중단되며 상속인이 소송을 수계하는 형태로 진행되므로 구별이 필요하다.

2. 사단법인의 분열과 당사자적격

- 종종이나 교회 등이 분열되어 소송이 발생한 경우, “판례”는 당해 법률관계에 대한 총유재산의 관리처분권이 누구에게 있는지를 기준으로 구체적인 당사자적격을 판단한다. 단순히 단체의 회원이라는 사정만으로는 대표하여 소송을 제기할 당사자적격이 인정되지 않는다.

## **VI. 결론**

- 당사자능력과 당사자적격은 민사소송의 적법성을 담보하는 이중의 필터 역할을 한다. 당사자능력은 소송을 시작할 수 있는 인적·조직적 주체로서의 그릇을 심사하는 단계이며, 당사자적격은 그 그릇이 해당 분쟁에 합당한 실체적 권리 주체인지를 가리는 단계이다. 소송 실무에서는 원고와 피고를 지정할 때 이 두 가지 요건이 모두 충족되었는지를 면밀히 검토함으로써 무익한 절차의 반복이나 소각하 판결의 위험을 사전에 방지하여야 한다.